

DAVID JOSE CANTALABIO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como

incurso nas penas do Art. 155 "caput" e Art. 14, II ambos do(a) CP(Denúncia), porque, segundo consta da denúncia, no dia 15 de setembro de 2016, por volta das 05 horas e 30 minutos, na Rua Marcelino Coelho, nº 54, Jardim Angela, neste município e comarca da Capital, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, 01 (uma) calça jeans, 02 (duas) blusas, 01 (uma) camisa polo, 01 (uma) bermuda, bens avaliados em 150,00 (cento e cinquenta reais) pertencente a vítima Silvanio Soares dos Reis. Consta, ainda, que a infração penal apenas não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2016 (fls. 53/54), o réu foi citado por edital (fls. 75) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 13 de abril de 2018.

Em 10 de abril de 2019, o réu foi pessoalmente citado (fl. 114) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/122).

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DAVID JOSE CANTALABIO, porque teria praticado o delito previsto no Art. 155 "caput" e Art. 14, II ambos do(a) CP(Denúncia).

Verifico que, ainda que não tenha sido determinada expressamente a revogação da suspensão do processo, o despacho de fls. 127 deu claro prosseguimento ao processo, apreciando a defesa prévia apresentada, de modo que deve ser considerado como termo final da suspensão, que se deu em 10 de abril de 2019.

Conforme se verifica nos autos, a pena mínima prevista para o delito em tela é de 1 (um) ano de reclusão e, mesmo com os acréscimos decorrentes da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando-se a diminuição em face da tentativa, a pena a ser aplicada não atingiria o patamar de 2 (dois) anos de reclusão. Referida reprimenda prescreve em 4 (quatro) anos, conforme determina o artigo 109, V do Código Penal.

Assim, desde logo se verifica a inutilidade da condenação do réu, pois a pena a ser aplicada seria atingida pela prescrição retroativa, a qual importa em extinção do "jus puniendi" estatal. Como se verifica da data do recebimento da denúncia até a data em que foi determinada a suspensão do processo passaram-se um ano e quatro meses e do dia em que foi dado prosseguimento ao processo após a citação até a presente data, passaram-se mais de três anos e sete meses, assim, somados os dois períodos, já decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos.

Não são desconhecidos os excelentes argumentos contrários ao reconhecimento da chamada prescrição virtual, com base na previsão de pena a ser aplicada, mas, agora, a Lei nº 11.719/08, ao alterar, entre outros, os artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal, trouxe como princípio orientador da persecução penal judicial a celeridade e economia processual, com possibilidade de absolvição sumária e realização de audiência única para instrução e julgamento (art. 397 e 400, Código de Processo Penal).

O legislador processual penal apenas cumpriu o disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, inserto pela EC 45/04, a assegurar como direito fundamental a todos "a duração razoável do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação", o que já era consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º, 1, por óbvio para evitar a persistência dos efeitos do processo penal.

Advertia o saudoso Professor das Arcadas Sérgio Marcos de Moraes Pitombo:

"Verificou-se que o acusado sofre o processo da imputação subjetiva ao julgamento final da ação penal condenatória, ainda que termine absolvido. Padece o procedimento e seu ritual. A função simbólica do processo de conhecimento traz-lhe a marca da infâmia. Tal averiguação, a inquirição prévia cuja forma procedimental varia, consoante os diversos sistemas processuais volta-se, assim, a duplo objetivo. Diminuir, minimizar, antes de tudo, o risco das acusações formais infundadas, temerárias e, até, caluniosas. Depois, evitar o custo, sem benefício, que tais inculpações desúteis trazem para a Justiça Penal"

(<http://www.sergio.pitombo.nom.br>, disponível em 12.09.2008).

E citou: "Observou Vicente Greco Filho: 'Já se sustentou que bastaria como justa causa para ação penal a descrição, na denúncia ou queixa, de um fato típico. A

doutrina atual, porém, à unanimidade, percebendo que a ação penal, por si só é, já, um constrangimento à liberdade individual, exige, para que a ação penal seja proposta e se mantenha, elementos probatórios que sirvam de fundamento razoável para sustentar esse constrangimento, o qual, caso contrário, seria ilegal'". (Manual de processo penal, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1997, § 14, p. 92).

Por isso advertem Aury Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró: "Também é preciso que se compreenda a instrumentalidade do processo penal, de modo que, para não aplicar uma pena, o Estado pode prescindir completamente do instrumento, absolvendo desde logo o imputado, sem que o processo tenha de tramitar integralmente. Isso permite que se exija, por exemplo, o pronto reconhecimento da prescrição pela provável pena a ser aplicada, com imediata extinção do feito" (Direito ao Processo Penal no prazo razoável. Rio de Janeiro. 2006, p. 127).

Para observância ao comando constitucional, exigência de prazo razoável do processo como direito fundamental, agora é imprescindível alargar o conceito de justa causa, para além do momento incoativo da ação penal, com constante verificação dos fundamentos de fato e de direito que sustentem desfecho útil, o que não se verifica no presente caso.

Como ensina Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, em seu judicioso trabalho O reconhecimento antecipado de prescrição, o interesse de agir no Processo Penal e o Ministério Público (Cadernos de Doutrina e Jurisprudência da Associação Paulista do Ministério Público, nº 7, págs 53/84): "O controle jurisdicional sobre as condições da ação é exercido mesmo em se tratando de processo penal. O princípio da obrigatoriedade da ação penal não cerceia o magistrado no exercício dessa atividade, quando proposta a ação penal nos limites estreitos dos artigos 41 e 43 do C.P.P.".

A clássica noção de interesse de agir, como condição da ação no processo civil e, que decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial e pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo, é extensível ao processo penal, pois como instrumento da atividade jurisdicional do Estado, o processo não sofre mutações substanciais quando passa do campo da justiça civil para aquele da justiça penal. A diferença entre eles é apenas de grau e não de natureza. Se razões de ordem prática aconselham a divisão do direito processual em civil e penal, certo é que ambos os ramos do processo apresentam um fundo comum.

A justa causa manifesta-se na figura do "fumus boni iuris", condição "sine quo non" para o exercício do direito de ação e que se subsume no interesse processual, confunde-se com o legítimo interesse do órgão acusatório. A inidoneidade impede que a pretensão deduzida possa ser reputada objetivamente razoável e, portanto, faz desaparecer a justa causa.

As regras determinantes do interesse de agir estarão presentes na ação penal quando o provimento jurisdicional invocado estiver perfeitamente identificado com as noções de adequação, necessidade e utilidade. Ausentes as regras determinantes do interesse de agir, carece a ação de justa causa. Sem que o "fumus boni iuris" ampare a imputação, dando-lhe contornos de imputação razoável, a denúncia ou queixa não pode ser admitida ou recebida.

Não é adequada a providência jurisdicional que impõe ao condenado pena, quer privativa de liberdade, quer restritiva de direito ou pecuniária, que não possa ser executada, restando como mero símbolo de reprovação judicial sem efetividade e sem corresponder, minimamente, às expectativas do autor e da sociedade.

O dever de exercitar a ação penal pública somente surge diante de determinada situação fática e da presença de condições previstas pelo próprio legislador. A ação penal está condicionada pelo ordenamento jurídico. Para avaliação dessas situações fáticas e jurídicas, o magistrado não dispõe de princípios e regras orientadoras diferentes daquelas de que são dotados os representantes do Ministério Público. O juiz é fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, na medida em que, discordando do pedido de arquivamento do inquérito policial, remete-o ao Procurador Geral de Justiça para que reaprecie, nos termos do artigo 28 do Estatuto Processual. Mas é também, e antes disso, fiscal das condições da ação e dos pressupostos processuais.

Sendo o interesse de agir a relação entre a situação anti-jurídica denunciada e a tutela jurisdicional requerida, disso resulta que somente há interesse quando se pede uma providência jurisdicional adequada à situação concreta a ser decidida. Assim, é preciso que se examine em que termos é formulada a exigência que se contém na pretensão para que se verifique da existência do interesse de agir. Como consequência, o interesse de agir exige antecipação, ainda que perfunctória, de análise do mérito. Quando apenas sanção máxima interferir no estabelecimento de um novo prazo prescricional, que é lícito aos envolvidos na lide, o Promotor de Justiça e o Juiz de Direito debruçam-se sobre os autos em busca dos elementos trazidos pelo artigo 59 como razões determinantes da escolha da quantidade de pena, para antecipação do juízo quantitativo, amoldação desse valor à tábua do artigo 109 e a consequente verificação concreta da existência de interesse de agir do Ministério Público.

Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência:

"De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso completo, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex-officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal. (RT.669/315)".

"Conquanto se admita que utilização da via jurisdicional, no ato de acusar, não leva, inexoravelmente, à imposição de pena, cabe averbar-se que o exercício da ação sobre indiscutível tom de falência quanto a aplicação completa da reprimenda, revelar-se-ia atividade sem qualquer atividade, eis que o provimento jurisdicional, se procedente a ação, desembocaria na prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a pena concretizada. (Recurso em Sentido Estrito 5889.413/0, 12.03.90, Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Juiz Walter Theodosio)".

Portanto, é de ser declarada ausência das condições da ação, por falta de justa causa, pois ainda que viesse a ser proferida sentença condenatória, esta seria de total inutilidade, posto que, pelo decurso do tempo e considerando-se as razões expostas, o Estado, inquestionavelmente, já perdeu o direito de punir, sendo imprescindível fazer cessar o sofrimento decorrente da desnecessária persecução penal daqueles submetidos às agruras de um processo que se sabe sem proveito, seja para quem for, o que não se demonstra razoável.

Ante o exposto, por falta do interesse de agir do Ministério Público, carece a ação de justa causa, motivo pelo qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVID JOSE CANTALABIO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 109, inciso V, artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição retroativa, com base na pena possivelmente aplicável em concreto.

Com o trânsito em julgado e certificada a inexistência de bens apreendidos, arquivem-se os autos, providenciando-se as anotações, averbações e comunicações necessárias.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

FABIOLA OLIVEIRA SILVA

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA